

1500772-30.2020.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500772-30.2020.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500772-30.2020.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON ALESSANDRO GONCALVES VALENCIO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JEFERSON ALESSANDRO GONCALVES VALENCIO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal afirmando que na madrugada do dia 14 para o dia 15 de setembro de 2020, na rua Daniel de Oliveira Carvalho, nº 111, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, arrombou a janela do estabelecimento comercial denominado "Da Terra Food", com uma barra de ferro e subtraiu, para si, uma bolsa de motoboy avaliada em R\$ 150,00; 200 latas de cerveja avaliadas em R\$ 700,00 no total; 200 latas de refrigerante avaliadas em R\$ 700,00 no total; 02 facas para sushi avaliadas em R\$ 900,00 no total e a quantia de R\$ 310,00 em dinheiro.

Segundo narrou denúncia, "o denunciado se dirigiu ao local dos fatos e, aproveitando-se da menor vigilância durante o repouso noturno e mediante arrombamento da janela com uma barra de ferro (cf. laudo pericial de fls. 28/311), ingressou no contêiner de lanches vítima e subtraiu os bens acima descritos, empreendendo fuga na sequência. Todavia, a ação delitiva foi flagrada pelas câmeras de

segurança do local (imagens às 23/25), sendo o denunciado prontamente reconhecido pela equipe de investigação (relatório de fl. 08 e fotografia de fl. 16), tratando-se de pessoa conhecida dos meios policiais pelo envolvimento em crimes nesta cidade. Interrogado formalmente (fl. 09), JEFERSON de imediato confessou a prática

do furto mediante arrombamento, esclarecendo que subtraiu os objetos e os trocou por drogas no ponto de vendas situado no bairro Cristo Redentor, tendo guardado parte dos valores para pagar sua estadia no Hotel Avenida, onde estava se hospedando."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia e audiência de instrução. O julgamento foi convertido em diligência, sendo posteriormente apresentadas alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores (...)
"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.
A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, pelo auto de avaliação de fls. 41 e, pelos laudos periciais de fls. 28/31 sobretudo, pela prova oral colhida.
A autoria também é certa.

A vítima, representante da empresa, Odair José Colucci, na fase policial, disse que "é proprietário de um trailer de lanches situado na Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 111, Jd. Primavera, nesta cidade de Porto Ferreira; que, na data dos fatos constatou que a janela da cozinha estava aberta, e o interior do trailer estava todo revirado; que, constatou então pelo circuito de monitoramento do local, que um indivíduo desconhecido entrou no local, mediante arrombamento da janela, vindo a utilizar um instrumento para abri-la, e furtou diversos produtos, sendo 200 latas de cerveja, avaliadas em R\$ 3,50 cada, 200 latas de refrigerante avaliadas em R\$ 2,50 cada, uma bolsa de motoboy avaliada em torno de R\$ 150,00, R\$ 310,00 em espécie e 02 facas de sushi avaliadas em R\$ 450,00 cada, objetos estes que não tinha dado falta quando registrou o boletim de ocorrência; que, toda ação durou cerca de quarenta minutos, sendo que o autor ainda separou um computador e uma impressora para furtá-los, mas por motivo que não sabe informar, acabou deixando os mesmos no local; que, o declarante narra que possui alarme porém no dia dos fatos, estava desligado por problemas técnicos; que, em seguida veio a delegacia registrar os fatos, sendo que o autor foi identificado como sendo Jeferson Alessandro Gonçalves Valencio, pessoa esta estranha a seu relacionamento; que, não teve prejuízo quanto ao conserto da janela." Não foi ouvido em juízo.
A testemunha de acusação, o policial civil Carlos Henrique Campos, em juízo, disse

que receberam informações de que uma pessoa estava promovendo a venda de produtos furtados na praça da estação rodoviária; tal pessoa estaria hospedada em um hotel nas proximidades da rodoviária. Observou que havia boletins de ocorrência de furto em dias anteriores. Localizaram o hotel e com as características da pessoa denunciada foram até o hotel Porto Ferreira onde só havia uma pessoa hospedada. Localizaram o quarto e chamaram o sujeito. Questionaram sobre o furto e ele confirmou que havia praticado a subtração; era usuário de crack. Foi levado até a delegacia. Não se recorda se o réu foi advertido de seus direitos no local. Réu confessou de livre e espontânea vontade. Não foram feitas buscas. Não conseguiriam pedir um mandado com aqueles elementos iniciais. Réu é de Leme e não é conhecido pela polícia. Não se recorda se o disse a respeito da quantidade de bebidas que pegou.

A testemunha de acusação, o policial civil Luiz Roberto Stringhetta, em relatório policial afirmou que "tendo aportado nesta unidade policial informações de que o investigado estaria hospedado no Hotel Avenida, localizado nesta cidade na Av. Dr. Jose Ferreira de Azambuja, e seria o autor do furto em tela, em companhia do escrivão Carlos, me dirigi até aquela localidade onde mencionada pessoa foi encontrada num dos quartos do hotel. Questionado sobre o furto, acabou por confessar a autoria; a res furtiva não foi recuperada, visto que o autor alegou tê-la deixado em uma "biqueira". Em juízo manteve sua versão. Disse que advertiu o réu de seu direito ao silêncio. Não se recorda das imagens. Havia uma divergência entre a versão da vítima e a do acusado sobre a quantidade de bebidas. Réu estava normal durante a diligência. Réu deu um endereço de Descalvado quando interrogado. Não sabe se ele tem familiares em Porto Ferreira.

JEFERSON ALESSANDRO GONCALVES VALENCIO, em declarações perante a autoridade policial, disse que: "é usuário compulsivo de crack e está morando na rua, sendo certo que em ocasiões esporádicas, fica hospedado no Hotel Porto Ferreira; que sobre os fatos relata que na madrugada do dia 15 de setembro estava sem dinheiro e com abstinência devido a falta de droga e por isso passou a procurar um local que pudesse praticar um furto visando auferir valores para o uso de crack; que ao passar por um trailer de lanche, situado na Rua Daniel de Oliveira Carvalho, resolveu furtá-lo; que o interrogando arrombou a janela, usando para tanto, uma barra de alumínio que estava pelo chão, a qual usou para fazer uma alavanca e abrir a janela; que após isso furtou aproximadamente duzentos reais em dinheiro, cervejas, refrigerantes e uma bolsa de alça; que todos os objetos do furto, o interrogando trocou por droga no ponto de venda situado na praça do bairro Cristo Redentor; que apenas guardou os valores para se hospedar no Hotel Porto Ferreira; que nesta data estava dormindo no hotel, quando pelo local chegaram dois policiais civis, e indagaram sobre o furto ora apurado, tendo o interrogando de imediato confessado a autoria delitiva; que está arrependido pelo crime que cometeu; que não conhece os policiais que o detiveram; que tem antecedentes por furto." Em juízo manteve sua versão. Disse que pegou no máximo 10 latas de coca e 8 de cerveja. Não tinha como levar 400 latas. Pegou R\$280,00 em dinheiro. Pegou 2 máquinas de passar o cartão. Pegou a bolsa. Não pegou faca. Explicou como entrou no estabelecimento. Já respondeu outros processos por furto. Pegou a mochila para levar as latas. Não cabiam 400 latas. Já foi internado para tratar seu vício. No presídio não faz uso de drogas. Hoje é pastor.

Independentemente de o acusado ter confessado os fatos, as imagens de fls. 23/25 não deixam dúvidas a respeito da autoria.

Todavia, não há nenhum elemento colhido em juízo que permita concluir, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que os objetos subtraídos foram outros que não aqueles declinados pelo réu.

De notar que a diligência policial foi ilegal. Não havia justa causa ("fundadas razões") para a diligência no quarto do réu. Se o objetivo era fazer tão somente a identificação dele (conforme relatou o investigador Carlos, na condição de testemunha, em resposta à pergunta do MP), isso seria absolutamente possível por outros meios.

O local estava abrangido pela inviolabilidade de domicílio e não se faziam presentes nenhuma das hipóteses autorizadoras para ingresso sem mandado judicial. O consentimento do acusado não foi comprovado, ônus que é, conforme posição pacífica dos tribunais superiores, da acusação (até porque, se alegado pela acusação, por força do art. 156 do Código de Processo Penal, caberia a ela a prova). Tanto não se faziam presentes que o policial Carlos, em resposta a um questionamento feito pelo representante do Ministério Público, disse que não pediu o mandado por não existirem condições para tal. Ele mesmo apontou que para pedir um mandado de busca seriam necessárias outras diligências. Ora, se não haviam condições para ingressar no quarto do réu com mandado judicial, com razões mais fortes ainda, conforme a jurisprudência do STF e do STJ, não haviam condições para fazê-lo sem mandado.

A situação se torna peculiarmente mais grave quando temos em vista a preocupação do constituinte com o tema, o qual sequer permite que qualquer um, inclusive os presos, sejam submetidos à identificação criminal:

Consta do art. 5.º do texto constitucional:

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

Ou seja, o que a constituição permite, no máximo, é a identificação criminal quando nas hipóteses previstas em lei. Isto é, muito longe de autorizar o ingresso em domicílio.

Desta forma, se o objetivo dos agentes públicos era, realmente, a identificação da pessoa imputada, deveriam, em conformidade com o direito, inicialmente exigir a identificação civil; somente podendo proceder à identificação criminal se houvesse algum problema com tal identificação civil (nos termos dos incisos I, II, III e VI do art. 3º da Lei 12.037/2009), constasse de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações (inciso V) ou mediante despacho da autoridade policial determinando ser a diligência necessária à investigação (IV). Jamais poderiam ter ingressado, ausentes mandado judicial ou as hipóteses permissivas do texto constitucional, no quarto do hotel onde habitava, ainda que momentaneamente, a pessoa imputada.

Digno de nota que, sem mesmo sem considerar o excesso da violação de domicílio para a diligência, a acusação não juntou qualquer documento que pudesse comprovar sequer o despacho da autoridade policial para a realização da identificação criminal (como exige a lei).

O documento de fls. 08 indica que os investigadores realmente teriam agido mediante algum despacho da autoridade policial, mas no relatório que fizeram a ela nada mencionaram acerca da identificação, apenas trataram da autoria e materialidade do delito. O que reforça a percepção de que de diligência para identificação não se tratava.

Quanto ao ingresso no quarto, tampouco servem como justificativas as palavras do réu conforme relatadas pelos policiais, vez que feitas sem as devidas advertências ao acusado de suas garantias processuais (STF, RHC 122.279/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 30/10/2014; STF, RHC 170.843 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 01/09/2021).

Entretanto, as filmagens feitas no estabelecimento onde o delito se consumou constituem fonte independente, servindo como prova da autoria conforme §§1º e 2º do art. 157 do Código de Processo Penal.

A existência de sistema de segurança e de vigilância eletrônica não torna o crime impossível, conforme entendimento do STJ:

Recurso especial representativo de controvérsia provido para: a) reconhecer que é relativa a inidoneidade da tentativa de furto em estabelecimento comercial dotado de segurança e de vigilância eletrônica e, por consequência, afastar a alegada

hipótese de crime impossível; b) julgar contrariados, pelo acórdão impugnado, os arts. 14, II, e 17, ambos do Código Penal; c) determinar que o Tribunal de Justiça estadual prossiga no julgamento de mérito da apelação. REsp 1385621/MG, Rel. Min. Rogerio Shietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015. Tema 924 dos Recursos Repetitivos.

Súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo (artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal): para sua caracterização é necessário que a violência seja praticada contra o obstáculo que dificulta a subtração e não contra a própria coisa. Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal é expressamente exigida a perícia, a qual, entretanto, conforme jurisprudência, pode ser substituída por provas testemunhais quando os vestígios tiverem desaparecido. No caso em exame, houve deterioração em janela localizada no terço médio da porção posterior do contêiner; conforme laudo de fls. 28/31.

Como os valores subtraídos são inferiores a um salário mínimo, porém superiores a 10% deste índice, afasta-se a insignificância, mas possível a figura privilegiada, a qual só não incide por conta da ausência de primariedade.

Configurado, assim, o delito de furto qualificado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas

circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de $1/8$, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. (...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...) Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Na primeira fase da dosimetria é possível a utilização de fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao fato objeto da acusação, pois a exigência de trânsito em julgado anterior é relativa somente à reincidência. Neste sentido se orientam as duas turmas do STJ ("A condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal", STJ, 5ª Turma, HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013; em sentido análogo STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1470846, Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 03/09/2015).

A folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária.

STJ, HC 291.414/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016.

Neste aspecto, a condenação nos autos 1500034-93.2020.8.26.0318 constitui mau antecedente a ensinar a fixação da pena em três anos de reclusão e 68 dias-multa.

Segunda etapa. Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (autos 0006057-60.2017.8.26.0318). Conforme dispõe o art. 67 do Código Penal, a confissão só tem valor preponderante quando associada à personalidade do réu. No caso, a confissão foi feita sem qualquer demonstração de arrependimento resumindo-se à confirmação do já explicitado no flagrante, de modo que deveria prevalecer a reincidência com um aumento de 1/6 (um sexto). Todavia, tendo em vista a função constitucional dada ao STJ, principalmente na alínea "c" do inciso III do art. 105, e a consolidação do entendimento pela Terceira Seção, a qual reúne todos os ministros das turmas com competência criminal da corte, faço a compensação das circunstâncias e mantenho a pena no patamar indicado.

Terceira etapa. A causa de aumento do repouso noturno verifica-se quando o ato é cometido entre o pôr e o nascer do sol, seja o local residência ou estabelecimento comercial (AgRg no REsp 1.251.465 – MG, rel. Min. Gilson Dipp, 2.10.2003), mesmo quando desocupados ou inabitados (STJ HC 29153 – MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 4.2.2014), e aplica-se a todas as figuras do furto, seja ele simples, privilegiado ou qualificado (ver STF HC 130952/MG, rel. Min. Dias Toffoli, 3.5.2016, e Nucci, Código Penal comentado, glosa 14 ao art. 155). No caso, o crime de furto foi realizado de madrugada.

Diante da reincidência, da negativa das circunstâncias negativas e do montante de pena fixado, não incide a Súmula 269 do STJ, razão pela qual fixo o regime fechado; vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos em razão dos maus antecedentes (inciso III do art. 44 do Código Penal). Impossível a suspensão condicional da pena em razão da extensão da sanção.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR JEFERSON ALESSANDRO GONCALVES VALENCIO à pena de reclusão, pelo prazo de quatro anos, em regime inicial fechado, bem como a 68 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 25 de fevereiro de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA